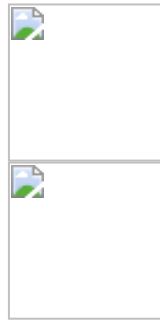


作者：[徐萍周昕](#) 金杜律师事务所公司[并购部](#)



引言

近十年来，随着中国经济发展和企业实力增强，中国企业投资迅速发展。商务部数据显示，2002年中国境外投资额为27亿美元，2005年达到123亿美元，2010年跃居590亿美元，连续上了几个台阶。2012年中国企业境外投资额达到878亿美元，比2011年增长了17.6%，占当年全球跨国直接投资额的6.3%，列在美国、日本之后，居全球第三。截至2012年底，中国累计对外投资额超过5300亿美元，年均增长35%。

此外，2013年1月至10月，我国非金融类对外直接投资695.2亿美元，同比增长19.5%。从投资的国家地区分布看，除对亚洲地区的投资下降5.2%外，对其他地区的投资均实现快速增长，对欧洲和北美洲投资增幅分别高达218.4%和135.2%。从投资的行业构成情况看，近九成投资流向商务服务业、采矿业、批发和零售业、制造业和建筑业五大门类。

为进一步支持中国企业境外投资活动，中国政府表明了放宽境外投资监管的态度和趋势。在2013年12月3日举办的第五届中国对外投资合作洽谈会（以下简称“外洽会”）上，国务院副总理汪洋表示，未来五年中国对外投资将达5000亿美元，中国政府将加快推进以核准制逐步向备案制为主的管理方式转变，确立企业和个人对外投资的主体地位，规范审批方式，减少审批环节，缩短审批时间，为中国企业“走出去”松绑。根据国务院2013年12月2日发布的《政府核准的投资项目目录（2013年本）的通知》（“《通知》”），除了中方投资10亿美元及以上项目、涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目由国务院投资主管部门核准外，其他中央管理企业投资项目和地方企业投资3亿美元及以上项目报国务院投资主管部门备案。

虽然在中央层面，《通知》的落实还需境外投资三大主要监管部门（发改委、商务部门和外汇部门）出台具体操作性的部门规章作为指引，但是目前在上海自贸区率先适用的境外投资项目备案制度可视为是此改革的试点。本文将对自贸区的境外投资备案管理制度及其影响作出分析和评述。

自贸区法规体系

2013年9月27日，国务院批准了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》（以下称“《总体方案》”），其中明确了在中国（上海）自由贸易试验区（以下称“自贸区”）改革境外投资管理方式、构筑对外投资服务促进体系，包括对境外投资开办企业实行以备案制为主的

管理方式、对境外投资一般项目实行备案制、加强境外投资事后管理和服务以及支持自贸区内各类投资主体开展多种形式的境外投资。

随后，上海市人民政府制定并公布了相关的配套法规，包括《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区境外投资开办企业备案管理办法》等。自贸区的两套境外投资备案管理办法分别对境外投资项目和境外投资开办企业作出规定，与发改委和商务部门分管项目投资和企业设立的自贸区外管理体制思路相同。自贸区管理委员会（以下称“管委会”）同时作为权限内企业境外投资项目和境外投资开办企业的备案机关。

至2013年12月2日，为加大对自贸区实体经济发展以及跨境投融资的金融支持，中国人民银行发布《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》（以下称“《人行30条意见》”），在创新自贸区特有账户监管体系、探索投融资汇兑便利、扩大人民币跨境使用以及深化外汇管理改革等诸多方面，指明了改革的方向，并提出将按照风险可控、稳步推进原则，尽快制定相应细则组织实施改革措施。

自贸区作为推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，突破了部分现行的境外投资的管理制度，将自贸区内企业境外投资由核准制改为备案制，并通过自由贸易账户推动相关跨境融资活动的发展，提高了境外投融资便利化程度。以下我们将具体比较自贸区内外境外投资及其相关融资活动管理方式的异同。

自贸区外境外投资项目管理

自贸区外，发改委境外投资项目核准包括项目前期信息报告制度和项目核准制度。其中，项目核准制度对一般项目和特殊项目作出区分。对于中方投资额1亿美元及以上的境外收购和竞标项目，中国企业在对外开展实质性工作之前，需向国家发改委报送项目信息报告。

对于一般项目的核准，中方投资额3亿美元及以上的资源开发类、中方投资额1亿美元及以上的非资源开发类境外投资项目，由国家发改委核准。地方企业实施的中方投资额3亿美元以下的资源开发类、中方投资额1亿美元以下的非资源开发类境外投资项目，由省级发展改革部门核准；中央管理企业实施的上述境外投资项目，由企业自主决策并报国家发改委备案。其中，对地方企业实施的中方投资额3000万美元以上至3亿美元以下的资源开发类、中方投资额1000万美元以上至1亿美元以下的非资源开发类境外投资项目，省级发展改革部门在下发核准文件前，需报国家发改委登记。

对于特殊项目的核准，前往未建交、受国际制裁国家，或前往发生战争、动乱等国家和地区的投资项目，以及涉及基础电信运营、跨界水资源开发利用、大规模土地开发、干线电网、新闻传媒等特殊敏感行业的境外投资项目，不分限额，由国家发改委核准，或由国家发改委审核后报国务院核准。

属于国家发改委或国务院核准的项目，企业须提交项目申请报告。国家发改委在20个工作日内完成核准或向国务院提出审核意见，经批准可延长10个工作日。

自贸区内境外投资项目管理

自贸区内，管委会对注册地在自贸区的地方企业实施的上海市权限内的境外投资一般项目，实行备案制管理。参考上海市的核准权限，适用管委会备案的境外投资项目限额为资源开发类的中方投资额3亿美元以下、非资源开发类的中方投资额1亿美元以下。限额以上的境外投资项目仍然由国家发改委核准。

对于特殊项目的核准，自贸区内的规定与自贸区外基本一致，区别仅在于增加了发改委认定“敏感国家和地区”和“敏感行业”的权力。

自贸区保留了项目前期信息报告制度和地方重大境外投资项目的登记制度。对于中方投资额1亿美元及以上的境外收购和竞标项目，需向国家发改委报送项目前期信息报告。对于地方企业实施的中方投资额3000万美元以上至3亿美元以下的资源开发类、中方投资额1000万美元以上至1亿美元以下的非资源开发类境外投资项目，虽然由管委会备案，但需报国家发改委登记。

适用备案制管理的企业仅需上报自贸区境外投资备案表并提交相关材料，无需制作项目申请报告。管委会在5个工作日内出具境外投资项目备案意见。

与自贸区外类似，取得项目备案意见是办理其他手续的前提，企业必须凭项目备案意见办理商务、外汇、海关、税务等相关手续。

自贸区外境外投资开办企业管理

自贸区外，商务部门对设立境外投资实体进行核准并颁发《企业境外投资证书》。

在与我国未建交国家的境外投资、特定国家或地区的境外投资、中方投资额1亿美元及以上的境外投资、涉及多国（地区）利益的境外投资或设立境外特殊目的公司由商务部核准。地方企业实施的中方投资额1000万美元及以上至1亿美元以下的境外投资、能源矿产类境外投资或需在境内招商的境外投资由省级商务主管部门核准。

上述境外投资的投资主体须提交申请书和其他相关文件。属于商务部核准的境外投资，核准期限为30个工作日；属于省级商务主管部门核准的境外投资，核准期限为20个工作日。

中央管理企业实施1亿美元以下的境外投资和地方企业实施的中方投资额1000万美元以下的境外投资只须提交《境外投资申请表》，其中前者由商务部核准，后者由省级商务主管部门核准。商务部门的核准期限为3个工作日。尽管自贸区外金额较小的境外投资的商务部门核准适用简易程序，但是在项目核准阶段仍然需要由省级发展改革部门核准。

自贸区内境外投资开办企业管理

自贸区内，管委会对注册在自贸区的企业实施的权限内境外投资，实行备案管理。

涉及与我国未建交国家（地区）的境外投资、特定国家（地区）的境外投资、涉及多国（地区）利益的境外投资、设立境外特殊目的公司、能源矿产类境外投资、需在国内招商的境外投资等，仍按照《境外投资管理办法》执行，由相应商务部门核准。

自贸区对境外投资开办企业未能明确管委会的管理权限，上述保留核准制的境外投资类型中也删除了中国企业实施的“中方投资额1亿美元及以上的境外投资”和地方企业实施的“中方投资额1000万美元及以上、1亿美元以下的境外投资”，似乎有意提高企业备案的规模上限。

通常情况下，申请境外投资备案的企业仅需提交境外投资备案申请表及其法人身份证明文件。管委会在收到申请材料后5个工作日内完成备案并制发《企业境外投资证书》。

境外投资开办企业的程序在取得项目备案意见之后进行。企业必须持《企业境外投资证书》办理外汇、海关、外事等相关手续。

自贸区外关于境外投资的跨境融资政策

自贸区外，人民银行以及外管局分别对企业的账户资金划转以及本外币跨境融资进行监管。

在企业账户监管方面，目前除部分试点政策的特殊许可之外，境内区外企业在境内银行只能开设境内账户，该等账户内资金的跨境划转受到人民银行与外管局的相关监管，无法如离岸账户内的资金一般跨境自由划转，因此，当其被用于为境外投资开办的企业提供融资支持时就会受到诸多限制。

具体而言，如果境内区外企业拟借入外债为其自身境外投资提供资金支持，当借入外汇外债时，内资企业的中长期外债须经发改委批准，短期外债须经外管局核定余额，该等外债资金可以用于符合其经营范围的境外新设投资或并购投资，但不得用于放款；当借入人民币外债时，除部分试点地区另有规定外，也受限于上述相关部门的批准。

如果境内区外企业拟向其境外投资开办的企业提供股东资金支持，可采取向境外被投资企业提供对外放款的方式。当选择以外汇进行对外放款时，其放款额度的确定与展期、以外币资金池作为放款来源等事项均须获得外管局的核准；相较而言，选择以人民币对外放款的监管则较为宽松，人民银行于2013年7月5日颁布的《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》（以下称“《人行简化政策》”）允许境内非金融机构直接向境内银行申请办理人民币境外放款结算业务，但是目前该等人民币放款业务的具体操作规则尚不明确，开展的还不是很广泛。

另外，如果境内区外企业拟为其境外投资开办的企业的境外贷款提供对外担保（即“内保外贷”），当选择以外汇进行对外担保时，其担保的设立及履约均须获得外管局的核准和登记；但选择以人民币进行对外担保时，虽然《人行简化政策》同样提出了宽松的监管措施，但未明确如何与外管局规定的事前核准和登记手续的衔接问题，仍存在一定的不确定性。

自贸区内关于境外投资相关的跨境融资政策

自贸区内，《人行30条意见》对现行账户资金划转以及本外币跨境融资政策作出了较大突破，进一步便利了区内企业对其境外投资开办的企业提供跨境融资支持。

在企业账户监管方面，区内企业可通过设立本外币自由贸易账户，实现分账核算管理，开展《人行30条意见》中提及的投融资创新业务，该等账户与境外账户、境内区外非居民账户以及其他自由贸易账户之间可自由划转资金，与区外普通结算账户之间也可以就经常项下业务、偿还贷款、实业投资以及其他符合规定的跨境交易需要划转资金（视同跨境资金划转管理）。

《人行30条意见》允许注册在自贸区内的外资企业、非银行金融机构以及其他经济组织根据经营需要按规定从境外融入本外币资金，有利于区内企业从境外获得融资成本更低的资金用于其境外投资、并购和为境外被投资企业提供资金支持。特别是，人民银行正在制定进一步的细则，明确具体资质要求、额度管理和操作规则，支持区内企业（包括中资企业）直接从境外融入利率较低的人民币资金。

另外，《人行30条意见》提出区内企业可以利用其自由贸易账户办理跨境融资、担保等业务，当条件成熟时，账户内本外币资金还可自由兑换。鉴于该等自由贸易账户能够与境外账户实现自由资金划转，因此，区内企业利用该等账户内的资金对其境外投资开办的企业进行对外放款或内保外贷等融资支持，将可能不再受限于区外繁琐且互相矛盾的行政审批程序，从而给区内企业的跨境融资带来极大的便利。

评述与展望

自贸区挂牌运行以来，总体上开局良好，取得了积极成效。截至11月22日，自贸区办理企业名称核准近6000户，完成新设企业1434家，其中外资新设企业38家，内资新设企业1396家。其中，不乏为了享受境外投资简便程序的内资企业。截至目前，已有区内企业按照新的管理办法完成了境外投资手续，据了解，该等区内企业仅用20日左右时间即完成了相关境外投资备案手续，自贸区对境外投资程序的简化确见实效。

然而，自贸区的境外投资管理体制改革仍处于探索起步阶段，相关配套措施尚不完善，执行过程中也存在不清晰之处，如下问题值得关注：

- 由于目前自贸区内部登记系统不完善且排队企业较多，据我们了解，目前申请区内企业注册所需时间较长，某些情况下可能需1-2个月。

- 尽管《人行30条意见》已经出台，甚至明确企业备案后可到银行直接办理汇出，无需做外管局的对外投资外汇登记，并提出诸多跨境融资的便利措施，但是针对这一规定外汇管理部门尚未就自贸区内的外汇监管出台具体细则。
- 与自贸区《境外投资项目备案管理办法》中明确规定管委会的管理权限与上海市平级相对比，自贸区《境外投资开办企业备案管理办法》没有明确管委会的管理权限，甚至在保留核准制的境外投资类型中删除了有关投资限额的规定。国家发改委利用外资和境外投资司司长孔令龙在自贸区情况说明会上提到“自贸区对境外投资项目改革的核心内容是对区内注册企业的境外投资一般项目实施备案制管理，并大幅提高了备案项目规模上限”。可见，自贸区有意提高企业备案的规模上限，甚至可能超过上海市的核准权限。但是鉴于目前规定尚不清晰，管委会对开办企业的备案权限还有待进一步明确。
- 自贸区在实行备案制的同时还保留了传统核准制的相关程序，区内外程序间应如何衔接？如报国家发改委地方重大境外投资项目的登记是否应当在管委会出具备案意见之前办理？由管委会负责提交还是由企业自行办理？
- 上海市政府副秘书长、自贸区管委会常务副主任戴海波在自贸区中外记者集体采访活动中表示，自贸区不会容忍空壳企业的概念，按照新的管理办法，企业注册以后，要进行年度报告公示，年度报告公示之后会产生经营异常名录，空壳公司、不运营的公司是没有生存空间的。但是在商业实践中，很多企业为境外投资目的仅会设立一个投资平台公司，而不进行经营活动，此类企业是否会被视为空壳企业，还是需要设立时明确经营范围为“对外投资”，该等“对外投资”的公司是否需满足更高的门槛要求？

对于两个管理办法在执行过程中的问题，管委会下一步可能会通过实施细则或通知的形式进行澄清或解释。另外，自贸区作为试验区，还将发挥示范带动、服务全国的积极作用。不排除其他中心城市未来可能试行同样或类似的境外投资备案制度。并且，国家发改委近期正在积极研究改善境外投资项目管理的有关具体措施，届时，上海自贸区境外投资备案制度经验可进一步向全国推广。